

0002060-74.2021.8.26.0368

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilson Miguel Gomes da Silva

Comarca: Monte Alto

Foro: Foro de Monte Alto

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... legal ou regulamentar. Assim, o tráfico de entorpecentes consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal.

Nesse sentido:

para configuração do crime de tráfico imputado ao réu, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a traditio, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Alto

Foro de Monte Alto

1ª Vara

Praça da Bandeira, nº 17, Monte Alto-SP - cep 15910-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002060-74.2021.8.26.0368 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002060-74.2021.8.26.0368

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2202562/2021 - DEL.POL.MONTE ALTO, 13794021 - DEL.POL.MONTE ALTO, 789/21/436 - DEL.POL.MONTE ALTO, 831/21/436 - DEL.POL.MONTE ALTO, 2202562 - DEL.POL.MONTE ALTO

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

Rafael Francisco de Mello

Juiz de Direito: Dr. Gilson Miguel Gomes da Silva

Vistos.

RAFAEL FRANCISCO DE MELLO, qualificado à fl. 121, e WILLIAN CARLOS FABIAN DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 27/29, foram denunciados e estão sendo processados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incursos nas penalidades do artigo 33, "caput" e artigo 35, "caput", combinado com o artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal; isto porque,

associaram-se, de forma interestadual, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, crimes de tráfico de drogas, incluindo o abaixo descrito. Consta, ainda, que no dia 8 de junho de 2021, pelo período da manhã, WILLIAN CARLOS FABIAN DE OLIVEIRA adquiriu de RAFAEL FRANCISCO DE MELLO e este remeteu 100 (cem) comprimidos coloridos de "ecstasy", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Decretada prisão preventiva dos acusados Rafael Francisco de Mello e Willian Carlos Fabian de Oliveira, bem como determinada a notificação dos acusados. (fls. 147/152) Determinado o desmembramento do feito em relação ao corréu Rafael Francisco de Mello (fl. 439).

Recebida a denúncia em relação ao corréu Rafael (fls. 625/626) e, através de seu Dr. Defensor, apresentou resposta escrita à acusação inicial (fls. 433/434).

Durante a instrução processual foi interrogado o réu Rafael (fls. 732/741), bem como foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação (Roberto - fls. 742/745; Jessica - fls. 746/748 e Marcelo - fls. 749/753) e uma testemunha arrolada pela defesa (Andrey - fls. 754/756).

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a total procedência da ação penal, a fim de que o acusado RAFAEL FRANCISCO MELLO seja condenado como incurso no artigo 33, "caput" e do artigo 35, "caput", ambos combinados com o artigo 40, inciso V, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, por entender suficientemente provadas autoria e materialidade delitivas. No entanto, pugnou que seja exasperada a pena-base em função do caráter ofensivo da droga apreendida (fls. 763/770).

A defesa, por sua vez, pugnou que seja julgada improcedente, quanto ao crime de tráfico e associação, alternativamente, aplicando ao réu a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da referida Lei de Drogas, por ser o acusado primário, nunca ter se dedicado às atividades criminosas nem ter sido integrante de qualquer organização criminosa. Requereu a aplicação do regime aberto para o cumprimento da pena, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (fls. 773/784).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada nos autos, através do Boletim de Ocorrência (fls. 7/8), pelo Auto de Exibição e Apreensão (fl. 16) e através dos Laudos Periciais (fls. 18/20) e mensagens através do aplicativo Whatsapp (fls. 65/69), bem como pela prova oral colhida nos autos.

Por sua vez, a autoria também é certa.

Em Juízo, o réu Rafael foi interrogado e disse: "alguns fatos, sim, não tem como fugir ou negar ou tentar esconder. É bem claro aí o que apareceu no processo, mas na questão da minha parte, eu já estava parando com todas essas coisas, que eu já tenho um passado meio que ruim com isso, mas como eu tenho alguma visão dessas coisas negativas ele veio perguntar algumas coisas para mim, tirar algumas dúvidas, questão de como que age, enfim, ele queria tirar algumas brisinhas dessas trouxas aí que a galera fala, desses entorpecentes, eu tirei algumas dúvidas dele, entendeu? Eu vi alguma coisa na internet e... é... conversei com ele alguma coisa superficial, a gente trocou algumas ideias, né, vamos dizer assim, como a gente fala no nosso meio. Eu acabei orientando ele, ajudando em algumas coisas, mas jamais em Correio, em enviar nada. Eu jamais ia participar de algum esquema criminoso. Eu fui na inocência de dar algum conhecimento, que eu já fui louco também, eu não tenho o porquê mentir, eu até falo isso de peito aberto, mas já passei por cima, graças a Deus. Foi uma ajuda, foi uma troca de ideias ali que ele tinha interesse e eu acabei... é... vamos dizer assim, Excelência e Promotor, eu acabei entrando nessa furada aí, eu fui tirar uma dúvida inocente para ele, fui querer ajudar em alguma brisa do Willian e tudo mais, entendeu? Eu sei que eu não enviei nada, eu não peguei droga na mão, pode ter certeza disso. O meu nome é Rafael e tudo certinho. De onde veio isso eu não sei. Eu sei que eu só vi uma coisinha ali na internet e expliquei para ele, ajudei ele numa questão ou outra, mas sem ter interligação direta com essas coisas. Eu sei como que é comprovado

isso, eu sei como que é visto essas coisas e tal. Eu não estou aqui para negar e se esconder, não, mas eu não tive participação de enviar nada, eu só conversei com ele, como está mostrando aí em algumas coisas, mas é isso, eu disse assim: "É tal valor, se você quiser você coisa, que eu estou me afastando". Querendo ou não, esse tipo de ajuda também é negativa e pesa para o meu lado, então pode foder a minha vida mais ainda, né? É tipo isso. (fls. 732/741).

Roberto, a testemunha arrolada pela acusação, narrou em Juízo que: "eu sou supervisor dos Correios, né, e a gente foi orientado que dentro dessa mercadoria poderia estar contendo drogas. Ela tinha passado pelo Raio-X lá no setor de tratamento em Bauru, né, aí lá eles viram que poderia ter alguma substância ilícita dentro, né? Diante disso, nós comunicamos aqui, a gente é orientado a comunicar a Polícia Civil, sendo que foi o que nós fizemos. Eu fui até à Delegacia e conversei com o delegado, o Dr. Marcelo, aí ele orientou a gente a segurar a mercadoria lá, né, e encaminhar um aviso para que o destinatário fosse retirar na agência. Como ele não foi, né, como ele não foi retirar, então eu entrei em contato com eles via telefone. ... Na verdade, eu conversei com a namorada do menino que era o destinatário, acho que era Jéssica o nome dela. Ela era... é... namorada dele, então eu entrei em contato com ela e informei que a mercadoria estava lá, que eles teriam que se dirigir até à agência dos Correios para retirar, mas eles não foram, eles não foram retirar. (fls. 742/745).

Jessica, a testemunha arrolada pela acusação, afirmou em Juízo que: "a gente recebeu um papel via Correio sobre essa encomenda, aí eu fiz a ligação perguntando se eu poderia retirar, sendo que lá no Correio disseram que não, que seria só o Willian, aí eu peguei e passei o recado para ele. ... Como ele disse que seria só ele, então eu não me preocupei com isso, eu só passei o recado para ele e ele ficou responsável. (fls. 746/748).

O Delegado de Polícia Marcelo, testemunha arrolada pela acusação, afirmou em Juízo que: "nesse caso nós realizamos a apreensão de uma encomenda, uma encomenda com conteúdo suspeito do Correio. Essa encomenda foi trazida até à Delegacia e nós fizemos a apreensão, aí nós conseguimos por meio de autorização judicial examinar esse conteúdo e apuramos que o conteúdo tratava-se de droga, tratava-se de ecstasy. No destinatário constante do envelope dessa encomenda, que havia sido apreendida, constava o nome do Willian, certo, por isso que foi pedida a prisão temporária do Willian, como também a busca e apreensão na academia, no local de trabalho dele, que também constava como endereço destinatário. Nós demos cumprimento a esse mandado de prisão temporária e também a esse mandado de busca e apreensão, sendo que logo no dia que nós demos cumprimento nós ouvimos o Willian e também a namorada dele, a Jéssica, tá? Nós ouvimos o Willian em interrogatório e a Jéssica em declarações, onde tanto um quanto o outro indicaram para nós que o Rafael, primo do Willian, de Apucarana, Estado do Paraná, é que havia encaminhado essa droga, ele é que havia enviado essa droga para Monte Alto. Então, nós apuramos que essa droga havia sido encaminhada para Monte Alto pelo Rafael de Apucarana, no Estado do Paraná. Como eu disse, foi ouvida a Jéssica em declarações e ouvido também o Willian em interrogatório. Em sede de cumprimento de mandado de busca e apreensão nós conseguimos apreender alguns aparelhos celulares esses aparelhos, claro, com a devida autorização judicial, foram periciados, eles foram analisados pelo Setor de Investigação da Delegacia, sedo que nós apuramos que em um desses aparelhos havia conversas no WhatsApp entre Willian e esse primo dele, o Rafael, conversas já há um certo tempo, onde essas conversas indicavam claramente que havia um conluio criminoso deles para o tráfico de drogas. Então, por meio dessas oitivas que foram realizadas e também por meio da análise desse celular nós conseguimos concluir que o Rafael teve, sim, envolvido para a prática de tráfico de drogas juntamente com o Willian." (fls. 749/753).

A testemunha arrolada pela defesa, Andrey, afirmou em Juízo que: "eu conheci ele, até ele conviveu dentro da minha casa com a minha família, sendo que o meu pai gostava dele, a minha mãe gosta dele. Ele sempre tratou todo mundo bem, sempre muito educado, gentil, organizado." (fls. 754/756).

Não foram arroladas outras testemunhas que pudessem afrontar o contexto probatório que se insere nos autos.

A prova é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta para ensejar a condenação do réu.

No tocante ao crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006.

Para a caracterização do tráfico de drogas basta a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33, da lei nº 11.343/06, in verbis: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, o tráfico de entorpecentes consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal.

Nesse sentido:

para configuração do crime de tráfico imputado ao réu, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância entorpecente, não se exigindo a traditio, para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página 512), salientando que eventual condição de usuário por si só não afasta a de traficante (Apelação Criminal nº 990.09.083925-2, Relator Marco Antonio Marques da Silva).

Noutro aspecto, cumpre lembrar que as afirmativas feitas pelo agente policial (fls. 749/753) têm a presunção juris tantum de serem verdadeiras, visto que está a serviço do Estado para garantir a segurança do cidadão e manter a ordem pública, cabendo a quem alegar eventual falsidade ou conduta ilícita da parte dele, prová-la ou, ao menos, trazer ao juízo indícios coerentes da dita irregularidade, o que não aconteceu no presente caso.

Neste sentido:

"Quanto ao depoimento de policiais, presume-se que agem eles no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, havendo que se repudiar sua palavra somente quando em flagrante dissonância com os demais elementos de convicção trazidos ao processo". (TJSP, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Devienne Ferraz, votação unânime, RT 727/473).

E ainda:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 - SP, Rel. Ministro Celso de Mello).

Assim, concluo serem válido e plenamente eficaz o depoimentos ofertado pelo agente da lei que efetuou a apreensão das substâncias entorpecentes, as quais foram remetidas pelo correio pelo acusado; aliás, não contamos com informações que desabonem ou desprestigiem a conduta do policial e sua forma de atuação.

Pontuo, ademais, que o Supervisor dos Correios Roberto, testemunha arrolada pela acusação, afirmou que os entorpecentes foram detectados através de Raio X, na unidade de Bauru-SP e, após a chegada da encomenda, foi comunicado o fato ao Delegado de Polícia Marcelo que efetuou a apreensão dos entorpecentes, conforme depoimento dele em Juízo (fls. 749/753).

Bom frisar, ainda, que no caso vertente não se percebe que pretendam os depoentes, gratuitamente, imputar ao acusado a prática delituosa, mormente tendo em conta que, conforme narrado pelo Delegado de Polícia às fls. 749/750: "realizamos a apreensão

de uma encomenda, uma encomenda com conteúdo suspeito do Correio. Essa encomenda foi trazida até à Delegacia e nós fizemos a apreensão, aí nós conseguimos por meio de autorização judicial examinar esse conteúdo e apuramos que o conteúdo tratava-se de droga, tratava-se de ecstasy. No destinatário constante do envelope dessa encomenda, que havia sido apreendida, constava o nome do Willian, certo, por isso que foi pedida a prisão temporária do Willian, como também a busca e apreensão na academia, no local de trabalho dele, que também constava como endereço destinatário. Nós demos cumprimento a esse mandado de prisão temporária e também a esse mandado de busca e apreensão, sendo que logo no dia que nós demos cumprimento nós ouvimos o Willian e também a namorada dele, a Jéssica, tá? Nós ouvimos o Willian em interrogatório e a Jéssica em declarações, onde tanto um quanto o outro indicaram para nós que o Rafael, primo do Willian, de Apucarana, Estado do Paraná, é que havia encaminhado essa droga, ele é que havia enviado essa droga para Monte Alto". Portanto as drogas eram destinadas ao comércio ilegal, indicativo claro, sem qualquer sombra de dúvidas, de que a droga realmente pertencia ao acusado Rafael e foram remetidas ao corréu Willian Daniel (este já julgado em apartado e condenado por este Juízo), embora o corréu Rafael negue que as tenha remetido pelo correio. Ademais, já se decidiu que para a formação do juízo de certeza razoável sobre o comércio de drogas de agente devidamente processado, não é indispensável à prova efetiva do tráfico. Tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente..."

Também é certo que esta espécie de criminalidade desenvolve-se de forma permanente e na clandestinidade, sendo que, os agentes policiais agem ou por provocação de alguma denúncia anônima ou em diligências bem-sucedidas.

Friso, outrossim, que o depoimento prestado pela testemunha Jessica (fls. 746/748) e Andrey (fls. 754/756) em nada colaboraram para o deslinde da presente ação penal. No mais, as alegações do acusado não tem o mínimo condão de prosperar, uma vez que restaram completamente destoantes do restante do contexto probatório, deixando patente que o réu busca fugir da condenação penal que lhe recai.

Cumprir anotar que o acusado, além de foragido - porque contra ele pesa mandado de prisão preventiva -, não arrolou qualquer pessoa da suposta família que o acolheu para corroborar com suas afirmações em Juízo, tampouco trouxe outras provas nos autos acerca de seu trabalho lícito, conforme por ele narrado às fls. 735/737. De outro vértice, embora tenha afirmado que não tenha sido ele o responsável pela remessa dos entorpecentes, o Delegado de Polícia Marcelo afirmou, às fls. 749/750, que o destinatário das drogas remetidas pelo correio era o corréu Willian e que: "no dia que nós demos cumprimento nós ouvimos o Willian e também a namorada dele, a Jéssica, tá? Nós ouvimos o Willian em interrogatório e a Jéssica em declarações, onde tanto um quanto o outro indicaram para nós que o Rafael, primo do Willian, de Apucarana, Estado do Paraná, é que havia encaminhado essa droga, ele é que havia enviado essa droga para Monte Alto." Outrossim, o Delegado de Polícia, à fl. 750, afirmou: "apuramos que em um desses aparelhos havia conversas no WhatsApp entre Willian e esse primo dele, o Rafael, conversas já há um certo tempo, onde essas conversas indicavam claramente que havia um conluio criminoso deles para o tráfico de drogas."

Assim, infere-se ser completamente destoante a tese defensiva do réu, indicativo este, de que tenta eximir-se de eventual reprimenda criminal que lhe recaia, não havendo qualquer fundamentação lógica as argumentações do acusado, as quais ficam rechaçadas.

Por sua vez, o laudo toxicológico anexado às fls. 18/20, concluiu que foi apresentada para análise a quantidade de "100 (cem) porções de material particulado, compactado na forma de comprimido" e "a análise do material descrito fez o uso de Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas e foi DETECTADA presença da substância TENANFETAMINA (MDA), constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 136 de 03/08/2020)".

A par disso, observo, por conseguinte, não haver dúvidas de que a forma da substância, ou seja, 100 (cem) comprimidos, com a presença da "substância TENANFETAMINA (MDA)", juntamente com as demais provas coligidas nos autos, indicam

claramente que a droga seria destinada para o tráfico.

Por todo contexto tecido nos autos, não há falar em absolvição por falta de provas como quer a douta defesa.

Desta feita, diante as circunstâncias que envolvem o acusado, tenho que o contexto probatório que se insere aos autos é robusto a indicar que o réu Rafael é envolvido na traficância de drogas, haja vista que, pela quantidade encontrada, seriam destinadas para terceiros consumidores.

Nesse cenário, o contexto probatório derivou em desfavor ao acusado.

No tocante ao crime previsto no artigo 35, caput, Lei 11.343/2006.

Para a caracterização do delito previsto no artigo 35, caput, Lei 11.343/2006, imprescindível a exata ocorrência das condutas descritas no tipo penal, in verbis: "Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:" No entanto, para que se configure o delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, indispensável se mostra a prova de que os envolvidos estavam associados com ânimo definitivo e de maneira estável para a prática do tráfico de entorpecentes.

Aliás, a este respeito, nos remetemos à doutrina de Cleber Masson e Vinícius Marçal, cuja lição é: "A união estável e permanente é a nota característica que diferencia a associação para o tráfico do concurso de pessoas (coautoria ou participação). No art. 35 da Lei de Drogas, portanto, é imprescindível o vínculo associativo, revestido de estabilidade e permanência entre seus integrantes" (Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019, p. 98).

Neste sentido, ademais, é firme a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:

"Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

No caso em tela, pelos elementos de prova colacionados aos autos, embora os acusado tenha realizado mensagens através do aplicativo Whatsapp (fls. 65/69) com o corréu Willian, relacionadas ao tráfico de drogas, não é possível afirmar, extreme de dúvidas, que o crime de tráfico de drogas praticado pelos corréus ultrapassou a esfera do mero concurso de agentes e que, além disso, estava configurada a expressão de um grupo criminoso estável e permanente, até porque, sobre isso, deixa patente pelos interrogatórios e demais provas colacionadas aos autos.

Portanto, no que diz respeito ao crime de associação criminosa, considero que o desfecho absolutório se revelava mais salutar. Logo, respeitado posicionamento diverso, não há prova cabal para se falar em crime de associação para o tráfico, conforme descrito na peça vestibular acusatória, salientando, ainda, a aplicação do corolário princípio in dubio pro reo.

Diante da ausência de elementos de convicção, entendo de rigor a absolvição, até mesmo porque "deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, extreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal" (Ac. un. da 6a. Câm., Ap. n. 126.465, de Guarulhos, rel. GERALDO FERRARI). É cediço que o magistrado deve pautar a sua atuação no livre convencimento, entretanto, deve existir nos autos provas que indiquem a certeza da autoria e materialidade do delito, caso contrário deverá incidir o princípio do "in dubio pro reo". Nesse sentido, oportuno o esclarecimento de Carrara:

"No processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. Condenação exige certeza... não bastando a alta probabilidade..., sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio" (In Prova Penal - Editora Aide - pag. 152).

O direito penal exige certeza para amparar o decreto condenatório, o que não foi obtido no caso concreto, ressaltando, na minha perspectiva.

A jurisprudência é vastamente pacífica de que as provas realizadas na fase inquisitiva só são aptas a embasar um decreto condenatório, quando comprovadas em Juízo, de forma a se mostrarem em harmonia com os demais elementos probatórios colacionados nos autos.

Princípio norteador do processo penal, bem como a garantia constitucional do estado de inocência.

Nesse sentido:

No processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer expressão algébrica. "Condenação exige certeza, não bastando a alta probabilidade, sob pena de se transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio". (RT 619/267).

Em matéria criminal, a prova deve ser límpida; qualquer dúvida deve vir a favor do imputado, porque temerária a condenação alicerçada em elementos eivados de incertezas (RT 523/375).

Uma condenação não pode estar alicerçada no solo movediço do possível ou do provável, mas apenas no terreno firme da certeza (RT 529/367).

Portanto, a absolvição no tocante ao crime previsto no artigo 35, "caput", da Lei 11.343/2006 se mostra mais salutar no caso sob análise.

Do mesmo modo, não há falar em aplicabilidade do artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006, uma vez que a encomenda, conforme documentos de fls. 09/11 destes autos, foi postada na cidade de Guarujá-SP, portanto dentro do Estado de São Paulo, de modo que não há comprovação de tráfico interestadual, motivo pelo qual afastou a incidência da majorante.

No tocante à tese defensiva.

No que tange à tese defensiva acerca do tráfico privilegiado, é cediço que para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso em tela, vislumbro a aplicação do benefício disposto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que o réu é primário (fl. 176), possui bons antecedentes e não há informações robustas nos autos que se dedique a atividades criminosas, não havendo provas de que sua introdução no narcotráfico não tenha sido eventual, portanto, preenche o requisito objetivo elencado na referida lei.

Desta feita, o fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade a ser reconhecida, razão pela qual as condenações e as imposições das correspondentes reprimendas previstas no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 são medidas que se impõem.

Passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao caput, do artigo 68, do CP. Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes. Anoto, no entanto, que as circunstâncias específicas do crime devem incrementar sua pena, porquanto possuía uma grande diversidade de drogas, inclusive sintéticas, que possuem alto poder de toxicidade, postura esta que acarreta maior repulsa frente à sociedade e deve servir para exasperar sua pena-base (art. 42, Lei de Drogas). Escudado nesses parâmetros, exaspero as penas base dos tipos em 1/6 (um sexto). Assim, para o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, a perspectiva perpassa ilesa, à minguada de atenuantes e agravantes. Na derradeira etapa, possível a aplicação do benefício disposto no § 4º, art. 33 da

Lei 11.343/2006, uma vez que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há informações robustas nos autos que se dedique a atividades criminosas. Por outro giro, tenho que a diminuição deve ser mínima, porquanto o réu remeteu as drogas pelo sistema dos Correios, utilizou nome falso e postou em cidade diversa a de sua residência, de modo a demonstrar capacidade de migrar ao crime organizado, haja vista sua desenvoltura para iludir e ilidir a fiscalização das autoridades policiais, a fim de praticar o crime em tela. Ainda, envolveu familiar residente em cidade distante, de maneira a alcançar maior grau de disseminação das drogas. Escudado nesses parâmetros, aplico o aludido benefício para reduzir a pena em 1/6 (um sexto) e passo a dosá-la em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa. Assim, torno a pena acima definitiva.

O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da ausência de informações seguras sobre a condição financeira do acusado.

O regime de cumprimento da pena corporal segundo a redação dada ao artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, pela Lei nº 11.464/07, e artigo 33, § 1º, alínea "a" c.c. § 3º, do Código Penal, deverá ser inicialmente o fechado, pela expressa determinação legal, bem como pela natureza nefasta do delito por ele praticado.

Deve ser levada em conta a disseminação de droga de alto poder alucinógeno, "ecstasy", como se infere das regras ordinárias de experiência, ligas ao maior prazer carnal, o que potencializa o risco aos jovens e jovens adultos, sem se olvidar de menores.

Tão é verdade que referida droga possui formato de comprimidos e sintetizada de forma colorida não à toa, mas para melhor propaganda de venda, servindo de atrativo junto aos consumidores juvenis.

Ora, é de pronta inteligência que a perpetração de tráfico denota personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo regime prisional.

Acresce ponderar que a concessão de regime aberto ou semiaberto ao autor de tráfico ilícito de substância entorpecente desidrata a eficácia intimidante da pena, tornando-a inócua.

Destaco que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 5º, inciso XLIII, determina um tratamento mais rigoroso a determinados delitos, dentre os quais os considerados hediondos e o de tráfico ilícito de entorpecentes.

Dessa forma, o legislador ordinário, embasado nas diretrizes fixadas pela Constituição Federal, instituiu que, nestes casos, dentre os quais se inclui o tráfico, o regime inicial de cumprimento da reprimenda deveria ser o fechado.

A imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena é, portanto, o reflexo esperado por conta do tratamento mais rigoroso dado pela Constituição da República ao crime de tráfico ilícito de drogas, o que significa que seu autor deve ser segregado e apenado com uma sanção que seja a medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para: a. CONDENAR o réu RAFAEL FRANCISCO DE MELLO, qualificado nos autos, como incurso nas penalidades do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06; em consequência, imponho-lhe a pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, mais o pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, cada qual no seu valor mínimo legal; b. ABSOLVER o réu Rafael de estar incurso nas penas do artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Condeno o acusado, ainda, ao pagamento das custas e do valor equivalente a 100 (cem) "UFESPs" (Lei Estadual nº 11.608, de 29/12/2003, observado, no entanto, o disposto no art. 12, da Lei nº 1060, de 5 de fevereiro de 1950).

Levando-se em conta que o réu está foragido, ou seja, contra ele há decreto de prisão preventiva; tendo em vista a quantidade de pena aplicada e o regime inicial



para o seu cumprimento; tenho que a custódia cautelar mostra-se necessária para se assegurar a aplicação da lei penal, pois o acusado poderá continuar em fuga. Além disso, sua ousadia na remessa e a especificidade das drogas, bem como a quantidade, demonstram que, em liberdade, sem decreto prisional, poderá tornar a delinquir, razão pela qual a prisão preventiva, também, se faz necessária para a garantia da ordem pública.

Assim, mantenho o decreto preventivo em desfavor do réu.

Expeça-se carta de guia de execução, oportunamente.

Autorizo a destruição das substâncias entorpecentes apreendidas que, ainda, não tenham sido incineradas, oficiando-se.

Transitado em julgado, procedam-se as anotações necessárias, comunique-se o TRE e cumpra-se a pena imposta.

P.I.C.

Monte Alto, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA